> **qualquer constrangimento ilegal sanável na via do *habeas corpus***. É que **a ação constitucional não se revela adequada para investigar as questões fáticas suscitadas a respeito de eventual suspeição de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório**.
>
> 3. Agravo regimental a que se nega provimento."
>
> (**HC 146.286-AgR/RS**, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/10/2017 – grifei)

Veja-se que os pontos elencados pelos impetrantes neste *writ* — "*(i) a condução coercitiva do paciente; (ii) a quebra do seu sigilo telefônico e de seus advogados; (iii) a divulgação dos áudios interceptados; (iv) o teor das informações prestadas pelo magistrado ao Supremo Tribunal Federal em reclamação; (v) o conteúdo da defesa preliminar apresentada pelo magistrado em queixa-crime contra si aforada pelo paciente; (vi) os fundamentos declinados por ocasião do recebimento da denúncia na Ação Penal n. 5046512--94.2016.4.04.7000; (vii) a postura do magistrado em determinados momentos das audiências de instrução da referida ação penal; (viii) as obras literárias lançadas tendo como tema a 'Operação Lava Jato' e os vínculos estabelecidos entre o magistrado e os respectivos autores; (ix) a participação do magistrado em eventos políticos ou com público antagônico ao paciente; (x) a predisposição do magistrado em condenar o paciente de acordo com matérias jornalísticas; e (xi) as considerações tecidas pelo magistrado em artigo acadêmico acerca de operação policial ocorrida na Itália*" — **foram**, de fato, **apreciados**, **estando cobertos pela preclusão**, pois transitados em julgado, e, mesmo que assim não fosse, não é esta a via escorreita para dirimir a controvérsia.

Contudo, em relação aos fatos novos indicados pelos impetrantes, assim concluiu o eminente Relator:

> "Da leitura dessa extensa lista de fatos levados ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça como indicativos da parcialidade do magistrado para o julgamento de processos envolvendo o paciente, não se encontra quaisquer **dos últimos**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

> **3 (três) invocados nesta atual impetração** para sustentar o mesmo pedido, a revelar que a pretensão está sendo exercida de forma original perante o Supremo Tribunal Federal, **embora o caso não se amolde às hipóteses elencadas no art. 102, I, alínea 'd', da Constituição Federal**.
>
> Diante de tal constatação, verifico, também nesta parte remanescente dos argumentos declinados na inicial, a **inviabilidade de conhecimento da impetração**, sob pena de se configurar a indevida prestação jurisdicional em supressão de instâncias, caracterizadora de ofensa às competências definidas pelo Poder Constituinte Originário aos órgãos do Poder Judiciário" (grifei).

Senhores Ministros, no meu entendimento, cada um daqueles fatos já foi objeto de análise em todas as instâncias do Poder Judiciário, estando, sim, ao contrário do quanto consignado no voto divergente, alcançados pela preclusão.

Além disso, como bem salientou o Ministro Relator, é inviável a reanálise de três fundamentos nesta via eleita, não só por supressão da competência de instâncias inferiores, mas também porque, na hipótese de **suspeição de magistrado, esta, sim, depende, a um só tempo, da produção de provas e da observância do princípio constitucional do contraditório**.

Com a devida vênia, há uma ampla estrutura sistemático-procedimental que indica à parte como e até em quais momentos certos temas podem ser invocados no processo penal.

Admitir a apreciação de suspeição em *habeas corpus* impetrado originariamente no STF, **depois de julgadas e rejeitadas três exceções sobre a matéria** e, ademais, com base em **prova ilícita**, desordenaria completamente os ritos e procedimentos da lei processual penal e iria contra toda a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

A suspeição, diferentemente do impedimento, não resulta de um vínculo objetivo exterior do juiz com a causa, apurável por meios ordinários de prova.

Na verdade, a suspeição decorre da presunção de um **estado psicológico favorável ou desfavorável** ao réu, em razão da **aparência de parcialidade** identificada em algum **fato objetivo exterior** (este, sim, comprovável pelos meios lícitos ordinários). É, portanto, uma incapacidade menos grave que o impedimento e **sujeita à preclusão**. Nesse sentido, pondera CELSO AGRÍCOLA BARBI:

> "A suspeição, diferentemente [do impedimento], se configura por circunstâncias em que o juiz tem o dever de se afastar da causa. Não o fazendo, a parte pode impugnar a sua atuação. Mas se o juiz não se considerar suspeito, e a parte não alegar, no prazo e forma legais, o defeito deixa de produzir qualquer consequência jurídica no processo; os atos e a sentença que ele proferir serão válidos. É como se o defeito não tivesse existido ou ficasse sanado." (BARBI, Celso Agrícola. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 11ª ed. atualizada por Eliana Barbi Botelho. Forense: Rio de Janeiro, 2002, p. 413)

Por dizer respeito à pessoa do juiz, e tendo em vista o poder de direção do processo que tem o magistrado desde o princípio da ação, **normalmente a alegação de suspeição deve preceder a qualquer outra defesa indireta** que tenha a parte contra seu adversário (CPP, art. 96). Isso também porque se presume ter a parte aceito o juiz perante o qual pratica normalmente os atos processuais, sem qualquer alegação de suspeição imediata.

Disso resulta que as **alegações ulteriores de suspeição** devem ser vistas sempre **com a máxima reserva**, apenas se justificando em casos de **motivos supervenientes**, avaliando-se, ademais, se a causa não foi criada propositalmente pela parte, caso em que a suspeição não se verifica (CPP,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

art. 256).

Na avaliação da suspeição, é indispensável que se observem dois aspectos do motivo alegado, o **exterior** e o **interior** (este último aferível apenas por **meios indiretos**).

As hipóteses de suspeição, legalmente previstas (CPP, art. 254), bem ilustram que deve haver uma **circunstância objetiva relevante**, que induza a aparência de parcialidade do juiz, para que a correspondente alegação seja avaliada por um tribunal:

a) CPP, art. 254, I – **amizade ou inimizade** com uma das partes (exteriormente aferível), que presumivelmente levem a um estado de embotamento da razão, por amor ou ódio (elemento interior, a ser aferido pelo tribunal de modo indireto);

b) CPP, art. 254, II, III, V e VI – **interesse pessoal**, direto ou cruzado, no resultado do processo (exteriormente aferível), que presumivelmente induzam um estado excepcionalmente alerta e ávido na mente do juiz (elemento interior, a ser aferido pelo tribunal de modo indireto); e

c) CPP, art. 254, IV – **ânimo favorável**, por motivo de **paixão de ordem moral**, **intelectual**, **política ou ideológica**, exteriorizado por meio de **conselhos a uma das partes — aferível por meios de prova lícitos e sindicável na via processual própria —**, que presumivelmente induza no juiz um **estado de simpatia pela parte aconselhada** (elemento interior, a ser aferido pelo tribunal de modo indireto).

A suspeição atinge a **independência pessoal** do juiz (JAUERNIG, Othmar. *Direito Processual Civil*. Trad. Port. F. Silveira Ramos. Almedina, Coimbra, 2002, p. 72) e, por isso mesmo, **não afeta o órgão jurisdicional**, senão que, uma vez reconhecida, implica unicamente o afastamento do juiz suspeito (agente jurisdicional), sem mudança de competência.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

Convém, ademais, não confundir o **perfil** de um magistrado com o **ânimo favorável ou desfavorável** a uma das partes. Todos os juízes, como seres humanos vivendo em coletividade, têm um ***background* ideológico**, **moral**, **cultural**, que os orienta, conscientemente ou não, a tomar essa ou aquela decisão.

A tomada de decisão sempre parte de **orientação espontânea para certas hipóteses**, decorrente de um rápido e, em grande parte, desconhecido processo de associação entre ideias concordantes e o descarte de ideias divergentes, até certo momento em que **o jogo mental colapsa em forma de decisão**. Esse processo não se resolve de uma só vez e pode frequentemente ser influenciado e controlado, ao menos em parte, pela própria mente pensante, por **meio de mecanismos conscientes de intervenção e calibração** (ver: KAHNEMAN, Daniel. *Rápido e devagar: duas formas de pensar*. Tradução Cássio de Arantes Leite. 1ª ed. 21ª reimp. Objetiva, Rio de Janeiro, 2012).

A **mundividência do juiz**, porém, não pode ser controlada por ele, já que faz parte da sua própria lente de filtragem do mundo, que está subordinada a elementos idiopáticos e ao ambiente em que o juiz viveu e se educou. Muitas vezes, deve-se admitir francamente, ela é **determinante para o resultado de um processo**, como observa ENRICO ALTAVILLA, no seu precioso trabalho sobre Psicologia Judiciária:

> "A intuição, precisamente devido a esta sua origem [experiências subconscientes], pode às vezes dar resultados preciosos, outras vezes criar um uniformismo perigoso para o juiz. A intuição é, certamente, uma voz que nasce do inconsciente, no qual se acumulou a nossa experiência e também a da coletividade, que, precedendo qualquer processo analítico de raciocínio, nos faz sentir como deve ter ocorrido um fato. Às vezes este juízo antecipado cristaliza-se tão potentemente na consciência do juiz, que não só as conclusões processuais não conseguirão modificá-lo, mas até ele, inconscientemente, se esforçará por adaptar esses

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

> resultados à sua convicção." (ALTAVILLA, Enrico. *Psicologia Judiciária*. Tradução de Fernando de Miranda. Coimbra, Almedina, 2003, vol. II, p. 480)

Os sistemas jurídicos, por isso mesmo, evoluíram para prever mecanismos de controle externo das decisões judiciais, de modo a evitar que os jurisdicionados ficassem completamente reféns de **processos mentais tão opacos**. Entre esses mecanismos, decerto a instituição de **tribunais colegiados** para a **revisão dos julgados** foi a mais importante e efetiva garantia contra a **tirania da cosmovisão** deste ou daquele magistrado.

A Constituição brasileira, sabiamente, vai além e, na própria composição dos tribunais, cria mecanismos de provimento de cargos que, ao menos em tese, asseguram a posse de magistrados **com idades e experiências de vida diferentes** e, portanto, presumivelmente com mundividências diversas. É assim, por exemplo, que temos:

a) a promoção de juízes de carreira, por **merecimento** (CF, art. 93, III; art. 107, II), de modo a prestigiar fatores que o tribunal considere relevantes no trabalho judiciário e que podem ser atingidos e aferidos com um **tempo menor** de exercício da magistratura;

b) a promoção por **antiguidade** (CF, art. 93, III; art. 107, II), tendente a distinguir os juízes de carreira com **mais tempo de atividade** e normalmente com maior idade;

c) a indicação de juízes oriundos **da advocacia** (CF, art. 94, *caput*; art. 107, I), com o intuito de assegurar, nos tribunais, uma **visão externa da carreira** e, ao mesmo tempo, próxima à das partes que litigam em juízo; e

d) a indicação de juízes vindos do **Ministério Público** (CF, art. 94, *caput*; art. 107, I), de sorte a assegurar que a **visão do órgão de persecução**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

penal do Estado possa também contribuir para o compósito que forma o colegiado dos tribunais.

A própria composição do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 101), mediante **indicação livre** pelo Presidente da República e aprovação do Senado Federal, dentro de um **vasto conjunto de cidadãos** que estejam em certa faixa etária e apresentem conhecimento jurídico notável e reputação ilibada, é um exemplo bastante ilustrativo de que **a Constituição intenta resolver o problema da clausura da mundividência pela diversificação dos pares dentro dos colegiados judiciais**.

Nada disso se confunde, repito, com suspeição.

Um observador atento pode, muitas vezes, estudando decisões anteriores, prever o resultado de um processo judicial a partir do **estilo** de certo juiz. No primeiro grau de jurisdição, isso é tanto mais facilitado pelo fato de que as decisões são tomadas monocraticamente. Tal circunstância não chega a caracterizar um vício jurídico; é, na verdade, a mera concretização rotineira do **processo humano de produção de decisões**.

Embora se possa discordar da decisão, e se possa inclusive discordar de todas as decisões de um juiz, por considerar-se o seu estilo detestável, isso está longe de ser motivo para anular pronunciamentos jurisdicionais. O caminho para solucionar essas situações, como já mencionei, foi pensado e estruturado adequadamente pelo constituinte, tendo sido colocado à disposição das partes: **o sistema recursal**.

A suspeição, diferentemente da mera mundividência, pressupõe uma **ligação peculiar** entre o juiz e o caso concreto. Não basta que o juiz seja **simpatizante de certas ideias**, casualmente controvertidas em certo processo, para que ele seja tido como suspeito; é preciso que ele tenha alguma **apetência especial** pelo resultado do processo que está em suas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

mãos, a ponto de **suscitar desconfiança sobre a honestidade do seu proceder**. E o primeiro aferidor dessa circunstância deverá ser o próprio juiz suspeito. Ele tem o dever de declarar-se assim, caso se sinta especialmente tentado a decidir em favor de um dos lados (CPP, art. 97).

Como a autoanálise nem sempre é suficiente, a lei estruturou um mecanismo de suscitação da suspeição (CPP, arts. 98 a 101), chamado pela doutrina de **exceção ritual** (TORNAGHI, Hélio. *Curso de Processo Penal*. São Paulo, Saraiva, 1980, vol. 1), a ser acionado, pela parte interessada, **enquanto o processo estiver nas mãos do juiz arguido de suspeito**. A não oposição da exceção no momento apropriado implica preclusão temporal. **E, mesmo quando oposta a exceção, uma vez julgada, se torna preclusa, por consumação, o tema da suspeição.**

Como dito acima, no caso dos autos, foram apresentadas três exceções de suspeição, todas rejeitadas pelos órgãos jurisdicionais competentes.

Seja como for, é nesse procedimento (*exceção de suspeição*), em que há **dilação probatória** e possibilidade de **contraditório entre o excipiente e o excepto**, que se pode alegar, provar e avaliar a suspeição.

O *habeas corpus*, pela própria limitação cognitiva que decorre de sua natureza de **ação documental**, não é remédio adequado para que se avalie a suspeição de um juiz. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal em inúmeros precedentes, já citados acima.

Em adição, deve-se considerar que a causa da suspeição normalmente deve ser **exterior ao processo**; a fonte deve estar situada em algum tipo de **relacionamento anterior ou**, **no mínimo**, **alheio ao caso concreto**. As moções e diálogos relacionados à tramitação da própria causa judicial — ou de causas similares — não devem, em princípio, gerar suspeição. Foi isso o que decidiu a Suprema Corte americana no caso **Liteky *versus* United States** [(92-6921), 510 EUA 540 (1994)].

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

A exigência de que a suspeição decorra de uma "**fonte extrajudicial**" é uma decorrência lógica do fato de que o juiz, durante o **processo de conhecimento**, deve mesmo ir **formando opinião sobre os elementos da causa**, inclusive sobre o próprio réu, para que, ao fim, possa emitir o seu veredito e, se for o caso, esteja em condições de dosar adequadamente a pena a ser aplicada.

Estranho seria que o juiz, num processo criminal, permanecesse completamente alheio e indiferente ao réu, e, ao final, **tivesse de julgá-lo nesse estado de atonia intelectual e emocional**.

Outro ponto de extrema relevância, e que desvanece os fundamentos da tese sustentada pelos impetrantes, é que o *habeas corpus*, por sua estrutura formal enxuta, não admite contraditório entre acusação e defesa, muito menos entre o arguente e o arguido de suspeição. E isso faz com que **decisão que eventualmente acolha a suspeição**, **neste caso**, **seja necessariamente tomada sem a observância da garantia do contraditório**.

O legislador constitucional dispôs na Carta de 1988 o **dever de preservar-se o contraditório e a ampla defesa como princípios inerentes ao Estado Democrático de Direito (CF, art. 5º, LV) e como valores supremos da Justiça**. **No caso em exame**, **o voto divergente acolhe uma pecha de suspeição** e condena um sujeito processual (o juiz de primeiro grau) ao pagamento de todas as custas do processo, **sem o necessário e indispensável direito de defender-se**. Com todas as vênias, a ofensa ao contraditório é manifesta.

Conforme nos ensina Nelson Nery Júnior, citado por Alexandre de Moraes, em sua obra *Direito Constitucional (10ª ed., p. 122)*: "*o princípio do contraditório, além de fundamentalmente constituir-se em manifestação do princípio do Estado de Direito, tem íntima ligação com o da igualdade das partes*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

e o direito de ação, pois o texto constitucional, ao garantir aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, quer significar que tanto o direito de ação, quanto o direito de defesa são manifestação do princípio do contraditório".

Entende-se o contraditório, atualmente, como garantia (aspecto negativo) e como dever de prestação (aspecto ativo). E é nessa linha que o art. 9º do novo Código de Processo Civil prescreve que "*o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício*".

Se é assim no processo civil, **com muito maior razão no processo penal**, em que os bens ou direitos em disputa são dos mais relevantes (o *ius libertatis* e o *ius puniendi*).

Enfatizo, no ponto, que o acolhimento da pretendida suspeição nesta via, em que não foram ouvidos a acusação nem o juiz contra o qual se imputa parcialidade, sem prova documental cabal de sua existência, seria uma **violação frontal ao princípio constitucional do contraditório**, quebraria totalmente o tratamento paritário que deve haver entre as partes no processo, impedindo que a acusação faça alegações e provas para contrapor-se àquelas apresentadas pela defesa. Significaria, portanto, atribuir-se-ia a um magistrado a pecha de parcial sem sequer ter sido ouvido no processo.

Notícias veiculadas em matérias jornalísticas não são provas incontestes; não estão nos autos e não se tem como verificar a sua veracidade apenas com base nelas mesmas.

Nunca é demais reiterar que sobre os fatos não se pronunciaram nem a acusação — repito, o MPF aqui atua apenas como fiscal da lei —, nem o juiz contra o qual se argui a suspeição, mesmo porque não há esse espaço na via estreita do *writ*, que, por esse motivo, exige **prova documental plena e não sujeita à refutação, para que seja admitida — o**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

que, conforme ora se demonstrou, não ocorre na hipótese dos autos.

Admitindo-se como superável tudo isso, resta analisar a **validade das provas que foram supervenientemente juntadas aos autos**. Trata-se de **documentos** que imputam ao ex-magistrado SERGIO MORO a participação em diálogos com membros do MPF. Se esses diálogos tivessem sido obtidos por meio lícito e tivessem tido o seu teor e autenticidade atestados oficialmente, alegadamente teriam a aptidão para comprovar a parcialidade do ex-juiz.

Antes dessa análise, cabe destacar o papel da Constituição como arcabouço de garantias e direitos fundamentais do cidadão. Essa ideia ganha especial sentido em Luigi Ferrajoli, o grande expoente do **garantismo penal**.

Para ele, o **garantismo** consiste em "*um modelo normativo de direito que nasceu e se desenvolveu no Direito Penal como sistema de limites à autoridade punitiva a garantia de direitos e liberdades. Todavia, o garantismo é um modelo normativo que pode ser extensivo à garantia de todos os direitos fundamentais; não só ao direito de liberdade, mas também aos direitos sociais, também aos direitos civis e políticos. Então, por representar a outra face do constitucionalismo, é o fundamento de uma teoria de uma democracia constitucional como um sistema de limites e vínculos a todos os Poderes; não só aos Poderes Políticos, mas também aos Poderes Privados; não só ao nível estatal, mas também ao internacional*" (disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=mwsbEV1tKvg>, acesso em 10/03/2021).

O garantismo não é exatamente novo; ele se insere numa longa tradição de tutela dos direitos contra abusos das autoridades públicas e, mais recentemente, dos potentados privados. A Magna Carta, de 1215, constitui a fonte primitiva do **devido processo legal**, a expressão mais genuína da ideia de garantia contra o arbítrio. Essa Carta, que concretizou

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

a *Rule of Law*, serviu também de base para a *Bill of Rights* norte-americana e muitos outros documentos político-jurídicos mundo afora, tendo sido o fundamento para as dez primeiras Emendas da Constituição dos Estados Unidos da América.

Chamo aqui a atenção para a 4ª Emenda, que dispõe sobre a inviolabilidade das comunicações e seus impactos e consequências ao devido processo legal:

> "O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres contra busca e apreensão arbitrárias não poderá ser infringido; e nenhum mandado será expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade confirmados por juramento ou declaração, e particularmente com a descrição do local da busca e a indicação das pessoas ou coisas a serem apreendidas".

Essa 4ª Emenda está na base da conhecida *teoria dos frutos da árvore envenenada* — a expressão foi cunhada no voto condutor do *Justice* Frankfurter no caso **Nardone v. United States** [308 U.S. 338 (1939)]—, no sentido de que **provas que tenham sido obtidas ilegalmente, ou quaisquer outras que delas derivem sem terem fonte independente, não podem ser utilizadas para nenhum efeito**, por serem radicalmente inválidas.

Como é sabido, a Carta de 1988, notadamente em seu art. 5º, abraçando uma **concepção garantista**, enumera quais os princípios, normas e valores que presidem o sistema constitucional brasileiro. Entre eles está, em fórmula sintética e elegante, a proibição do uso de provas ilícitas (CF, art. 5º, LVI):

> "**LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos**" (grifei).

Tal garantia, para além de ser um instrumento que assegura a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

fidelidade a princípios civilizatórios básicos, também sustenta o protagonismo salutar do processo como meio cogente de solução de conflitos não resolvidos por autocomposição, no ponto específico da produção da prova — que é, em muitos casos, o cerne do processo.

Se fosse permitido o uso da prova ilícita; se o Estado coonestasse a evidência arrebatada, surrupiada, colhida mediante fraude ou qualquer meio ilícito, os litigantes poderiam exercitar toda a sorte de transgressão em busca de evidências que sustentassem as suas alegações, de modo tal que o processo, em vez de um espaço de autoridade e pacificação, tornar-se-ia um campo para competição tresloucada por provas a todo custo.

Não é preciso especular muito para estimar que, em se criando um mercado de provas ilícitas, os incentivos para a prática de crimes seriam enormes, principalmente crimes cibernéticos.

Hoje, muitos aspectos da individualidade, da vida privada, do trabalho, dos negócios, enfim, da vida em geral das pessoas passam-se em meio eletrônico. Se o *hackeamento* fosse tolerado como meio para a obtenção de provas, ainda que para defender-se, ninguém mais estaria seguro de sua intimidade, dos seus bens, da sua liberdade: tudo seria permitido.

No caso em exame, as provas da alegada suspeição são arquivos de dados obtidos por *hackers*, mediante a violação ilícita dos sigilos telefônicos de dezenas de pessoas, conforme descoberto na Operação *Spoofing*, da Polícia Federal. Com a devida vênia dos que eventualmente possam entender de forma diversa, tenho que são **absolutamente inaceitáveis tais provas**, por serem fruto direto de crimes.

Entender-se de modo distinto, ou seja, que resultados de tais crimes seriam utilizáveis, mesmo que para a defesa de alguém, significaria, de forma transversa, **legalizar atividade de *hacker* no Brasil**.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

Faço a seguinte indagação: após um eventual julgamento favorável neste *habeas corpus*, alguém poderia promover, no futuro, o *hackeamento* de outras pessoas com o fim de **obter prova** para defender-se em processo penal? Estaria, tal agente, nesse caso, em **exercício regular de direito** que excluiria a ilicitude de sua conduta?

Se a resposta for afirmativa, do que francamente discordo, não é difícil imaginar o que ocorreria. Essa prática abjeta de espionar, bisbilhotar e violar a intimidade das pessoas, estaria legalizada. A sociedade viveria um processo de desassossego semelhante ao das piores ditaduras. Não é isso o que deve prevalecer numa sociedade democrática. A forma, sim, importa na democracia, tanto quanto o conteúdo.

Destaco, aqui, que é pacífico ser lícito **ao interlocutor da conversa poder gravá-la**. Nesse sentido, cito julgados desta Corte cujas ementas foram assim redigidas (com meus grifos):

> "AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. **Repercussão geral reconhecida**. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
>
> **É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro**."
>
> (**RE 583.937-RG-QO/RJ**, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009)

> "GRAVAÇÃO AMBIENTAL – INTERLOCUTOR – PROVA – VALIDADE. **É válida a utilização de gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, como meio de prova no processo penal** – recurso extraordinário n. 583.937, relator ministro Cezar Peluso, julgado sob o regime da repercussão geral. Ressalva de entendimento pessoal.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

> PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO. O artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal versa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente."
>
> (**RHC 112.428/DF**, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 11 a 18/12/2020)

> "AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. PROCESSO PENAL. INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201/1967. INADMISSIBILIDADE DO *HABEAS CORPUS*. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. **LICITUDE DE PROVAS OBTIDAS POR GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR INTERLOCUTORES**. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
>
> (**HC 191.873-AgR/SE**, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05 a 12/02/2021)

Todavia, coisa bem diversa de um participante da conversa gravá-la é alguém começar a monitorar outras pessoas, interceptando suas conversas (escritas, faladas, filmadas), sem delas participar, **violando a intimidade** de quem ele achar e/ou supor que lhe possa **oferecer eventual prova para defender-se** em um processo criminal.

Outra questão absurda, mas defensável sob essa errônea perspectiva, surgiria aí: a pessoa que quer defender-se em processo penal, **interceptando**, **sem autorização judicial**, **conversas alheias**, **poderia contratar outras para fazê-lo por ela**? A resposta seria afirmativa, caso se admitisse que isso seria um exercício regular do direito de defesa. Então, teríamos profissionais do crime de *hackeamento* oferecendo livremente os seus serviços.

A Constituição de 1988, preocupada com os direitos e garantias do indivíduo, acertadamente erigiu como cláusula pétrea a vedação de utilização de provas ilícitas no processo e proibiu taxativamente a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

interceptação telefônica sem autorização judicial. Essa a expressa dicção dos incisos XII e LVI de seu art. 5º, *verbis*:

> "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
>
> ….....
>
> XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
>
> ….....
>
> LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;"

Note-se, inclusive, que a regra insculpida no inciso LVI é taxativa ao **vedar** a utilização, no processo, de provas obtidas por meios ilícitos. O que falar então daquelas que são resultado de crime, como as conversas, citadas neste processo, fruto de delitos de **interceptação ilegal** de dados (art. 10 da Lei nº 9.296/96) e organização criminosa?

Destaco que este Tribunal, ao qual incumbe a nobre tarefa de guarda de nossa Constituição, tem diversos julgados repelindo a utilização, no processo, de provas ilícitas. Cito, *verbi gratia*, os seguintes (grifos inexistentes nos textos originais):

> "AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. QUADRILHA. CORRUPÇÃO PASSIVA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE 'QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA'. PERDA OU SUBTRAÇÃO DE PARTE DAS GRAVAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO NAS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. As provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, serem desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorram de outras fontes (...).

2. Assentou o Superior Tribunal de Justiça que, 'em matéria de provas ilícitas, o art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.690/2008, **excepciona a adoção da teoria dos frutos da árvore envenenada na hipótese em que os demais elementos probatórios não estiverem vinculados àquele cuja ilicitude foi reconhecida**'.

….....

4. Agravo Regimental a que se nega provimento."

(**HC 156.157-AgR/PR**, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018)

"I – '**HABEAS CORPUS': CABIMENTO: PROVA ILÍCITA**.

1. Admissibilidade, em tese, do *habeas corpus* para impugnar a **inserção de provas ilícitas em procedimento penal e postular o seu desentranhamento: sempre que, da imputação, possa advir condenação a pena privativa de liberdade**: precedentes do Supremo Tribunal.

II – **PROVAS ILÍCITAS: SUA INADMISSIBILIDADE NO PROCESSO (CF, ART. 5º, LVI): CONSIDERAÇÕES GERAIS.**

2. Da explícita **proscrição da prova ilícita, sem distinções quanto ao crime objeto do processo** (CF, art. 5º, LVI), resulta a prevalência da garantia nela estabelecida sobre o interesse na busca, a qualquer custo, da verdade real no processo: consequente impertinência de apelar-se ao princípio da

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

proporcionalidade – à luz de teorias estrangeiras inadequadas à ordem constitucional brasileira – para sobrepor, à vedação constitucional da admissão da prova ilícita, considerações sobre a gravidade da infração penal objeto da investigação ou da imputação.

III – GRAVAÇÃO CLANDESTINA DE 'CONVERSA INFORMAL' DO INDICIADO COM POLICIAIS.

3. **Ilicitude decorrente** – quando não da evidência de estar o suspeito, na ocasião, ilegalmente preso ou da falta de prova idônea do seu assentamento à gravação ambiental – de constituir – dita '*conversa informal*', modalidade de '*interrogatório*' sub-reptício, o qual – além de realizar-se sem as formalidades legais do interrogatório no inquérito policial (C.Pr.Pen., art. 6º, V) –, se faz sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio.

4. O privilégio contra a auto-incriminação – **nemo tenetur se detegere** –, erigido em garantia fundamental pela Constituição – além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do art. 186 C.Pr.Pen. – importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da advertência – e da sua documentação formal – faz **ilícita a prova** que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em '*conversa informal*' gravada, clandestinamente ou não.

IV – ESCUTA GRAVADA DA COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA COM TERCEIRO, QUE CONTERIA EVIDÊNCIA DE QUADRILHA QUE INTEGRARIAM: ILICITUDE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS, COM RELAÇÃO A AMBOS OS INTERLOCUTORES.

5. A hipótese **não configura a gravação da conversa telefônica própria por um dos interlocutores** – cujo uso como prova o STF, em dadas circunstâncias, tem julgado lícito – mas, sim, **escuta e gravação por terceiro de comunicação telefônica alheia**, ainda que com a ciência ou mesmo a **cooperação de um dos interlocutores: essa última, dada a intervenção de**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

> **terceiro, se compreende no âmbito da garantia constitucional do sigilo das comunicações telefônicas e o seu registro só se admitirá como prova, se realizada mediante prévia e regular autorização judicial**.
>
> 6. **A prova obtida mediante a escuta gravada por terceiro de conversa telefônica alheia é patentemente ilícita** em relação ao interlocutor insciente da intromissão indevida, não importando o conteúdo do diálogo assim captado. (...)"
>
> (**HC 80.949/RJ**, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/10/2001)

Saliento, ainda, que, mesmo se fosse juridicamente admissível utilizar-se de **diálogos obtidos criminosamente como prova em processo judicial** — o que entendo claramente **vedado**, **sem qualquer exceção**, **pela Carta Magna** (lembrando, mais uma vez, que a gravação da conversa por interlocutor não é crime) –, restaria ainda um enorme problema: pode-se confiar no conteúdo dos arquivos *hackeados*, sem qualquer perícia oficial em contraditório?

É fato que, num diálogo, a supressão ou inclusão de uma simples palavra pode mudar todo o seu significado. **Como confiar**, **então**, em provas fornecidas por criminosos?

Será que **uma perícia poderia atestar** que as conversas criminosamente interceptadas **são autênticas e exatamente fiéis**, sem acréscimo ou supressão de qualquer palavra? Não tenho certeza. E, mesmo que fosse viável fazê-lo, **é notória a impossibilidade de realização de perícia em *habeas corpus***, ação mandamental de natureza constitucional, cujo rito estreito não admite dilação probatória.

Não há mais espaço para elucubrações fantasiosas sobre juízes "antilavajatistas" ou juízes garantistas. Penso eu que todo magistrado tem a obrigação de ser garantista; o magistrado deve ter como pressuposto nos seus vereditos o cumprimento das leis e da Constituição.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

Deve ser garantista do Direito em geral.

Os direitos e garantias individuais devem ser preservados, independentemente de quem seja o réu.

Estivéssemos nós, hoje, apreciando provas obtidas por meio ilícito, cujo conteúdo não se sabe se é verossímil ou adulterado, no processo do Francisco, do Raimundo, ou mesmo de um Senador da República ou de um Deputado Federal, não estaríamos a discutir o aproveitamento de tais provas, pois, a esta altura, já estariam rechaçadas e desentranhadas dos autos, como manda a lei (CPP, art. 157, na redação dada pela Lei nº 11.690/2008).

Então, o que deveria mudar no caso sob análise? Por ser o HC extraído da Operação Lava Jato ou por ser o julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro, isso autorizaria uma exceção, uma mudança de entendimento? Absolutamente, não!

Todos os brasileiros são iguais perante a lei e merecem ter um julgamento justo, efetuado por juízes competentes, independentes e imparciais (Pacto de São José da Costa Rica, art. 8º, inciso I) e com base em provas lícitas.

Tenho a sensação, talvez idêntica à de milhões de brasileiros, que o novo material trazido aos autos muito provavelmente corresponda à verdade dos fatos que ocorreram à época; mas **estamos diante de diálogos obtidos por meio ilícito, mediante interceptação clandestina, sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica**.

E, como frisei, ainda que as provas fossem consideradas lícitas, não se pode assegurar que o seu conteúdo corresponda fidedignamente aos diálogos, pois podem ter sido alteradas, com adição ou supressão de palavras ou textos.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

Já está registrada nos anais desta Corte a célebre e acertada frase dita pelo eminente Ministro Gilmar Mendes: "*não se combate crime cometendo crime*".

Não podemos errar, como "se supõe" que errou o ex-Juiz Sergio Moro; como "se supõe" que erraram alguns membros do MPF. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um *looping* infinito de ilegalidades aceitarmos provas ilícitas (crime) para comprovar um suposto crime, praticado para apurar outro crime.

Registro: dois erros não fazem um acerto!

A Constituição garante, indistintamente, a todos brasileiros (e, aí, incluem-se o ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e também o ex-juiz Sergio Moro), **que são inadmissíveis**, **no processo**, **as provas obtidas por meios ilícitos** (art. 5º, LVI).

A prova trazida aos autos é ilícita, ilegítima e imprestável, e, portanto, impossível de ser aproveitada em sede de *habeas corpus*.

Por todo o exposto, **denego a ordem** de *habeas corpus*, por entender pela inviabilidade de comprovar-se, nesta ação constitucional de rito sumaríssimo, a suspeição alegada daquele que, então, era o julgador de primeiro grau, sem a necessária dilação probatória para demonstração, indene de dúvidas, dos diversos fatos alegados pelo impetrante, que não se afiguram, portanto, líquidos e certos.

É como voto.

Ministro **NUNES MARQUES**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

23/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

CONFIRMAÇÃO DE VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Apenas para aprimorar a dialética, retorno brevemente a alguns pontos do meu voto-vista. Vou pedir licença à Turma para fazê-lo.

Quanto à possibilidade de análise da questão em sede de *habeas corpus*, rememoro que esta mesma Segunda Turma possui diversos precedentes em que foi afirmada a possibilidade de conhecimento da alegação de quebra de imparcialidade por esta via. Como também nós entendemos - e isso é claro, o Ministro Fachin conhece bem e também a Ministra Cármen - que em HC é suscetível de se fazer revisão criminal.

Ao apreciar o HC 95.518, de minha relatoria, esta Turma assentou que:

"A alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de *habeas corpus* quando independente de dilação probatória."

Se nos autos estiverem os elementos pré-constituídos.

"É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado neste *habeas corpus*, sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria o *writ* (...)". (HC 95.518, Rel. Min. EROS GRAU, em que fui designado redator para acórdão, Segunda Turma, DJe 19.3.2014)."

"A temática da suspeição de magistrados também foi conhecida por este Tribunal nos seguintes julgados: RHC-AgR 127.256, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016; RHC 119.892, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.10.2015; HC 77.622, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 29.10.1999."

E há um clássico, Ministra Cármen, cujo número me escapa aqui, da Relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

"No caso em apreço, entendo que devemos fazer a distinção entre o que é, efetivamente, avaliação de fatos controvertidos e mera valoração das provas existentes nos autos e de informações públicas e notórias. Portanto, ainda que a análise em sede de *habeas corpus* tenha cognição limitada nos termos assentados pelo STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial das decisões das instâncias inferiores, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399)."

Como amplamente discutido neste caso:

"A fim de demonstrar a perda da parcialidade do magistrado, a defesa expõe 7 (sete) fatos que denotam a ausência de parcialidade da autoridade judiciária, quais sejam: (i) o deferimento da condução coercitiva do paciente e de familiares seus, ocorrida em 4.3.2016, sem que tenha havido prévia intimação para oitiva pela autoridade policial; (ii) a autorização para a interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, familiares e advogados antes de adotadas outras medidas investigativas;(...)."

E aqui, Ministra Cármen, lembro que eu rememorava a discussão que tivemos lá atrás, naquele célebre caso em que o Ministro Celso de Mello concedia a ordem por conta de monitoramento de advogados, o advogado Cezar Bitencourt.

Aqui, houve isso. E depois se disse que talvez o advogado também fosse investigado, porém se investigou uma banca de advocacia enorme, ainda que a provedora dos serviços fizesse a devida advertência de que assim estavam fazendo.

"(...) (iii) a divulgação, no dia 16.3.2016, do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas; (iv) o momento histórico em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados, pontuando os impetrantes que "[A]s principais figuras públicas hostilizadas pelos apoiadores do impedimento eram a ex-Presidente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

Dilma e o Paciente"; (v) a condenação do paciente, reputada injusta pela defesa técnica, em sentença proferida no dia 12.7.2017; (vi) na atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada pelo Desembargador Federal Rogério Favreto, no dia 8.7.2018, em decisão liminar proferida nos autos do HC5025614-40.2018.4.04.0000; e (vii) a aceitação do convite feito pelo Presidente da República eleito no pleito de 2018 para ocupar o cargo de Ministro da Justiça, a indicar que toda essa atuação pretérita estaria voltada a tal desiderato.

Ressalta-se que a apreciação dos fatos e das circunstâncias descritas neste HC não se confunde com a verificação interna da legalidade dos atos jurisdicionais praticados."

Isso eu disse no meu voto e estou a reiterar.

"Daí porque, com as devidas vênias, tenho por improcedente a tese lançada no voto-relator de que parte dos fatos alegados na impetração já teriam sido objeto de deliberação pelas instancias do Poder Judiciário."

E agora subscrita pelo Ministro Nunes Marques.

"Em primeiro lugar, é importante destacar que doutrina e jurisprudência admitem a utilização do *habeas corpus* como substitutivo da revisão criminal, tendo em vista a relevância constitucional dessa ação enquanto instrumento de proteção por excelência do direito fundamental à liberdade."

As provas estão nos autos - é isso que precisa ser examinado.

"Com efeito, o remédio heroico pertence à esfera da justiça constitucional sendo caracterizado precipuamente enquanto um instrumento rápido e imediato de tutela jurisdicional da liberdade de locomoção, que se destina a restaurar de pronto o *jus libertatis* assim atingido, ou impedir, também de forma breve e imediata, que esse direito acabe indevidamente ameaçado."

Vejam, Senhores Ministros, a confusão em que nós estamos hoje inseridos. Muito recentemente, o Relator, que, como ninguém, se debruça sobre este processo, reconheceu que todos os fatos processados e julgados em Curitiba, pela 13ª Vara, relativamente ao paciente, Luiz Inácio Lula da Silva, não deveriam lá estar, porque não guardavam relação com a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

corrupção na Petrobras. Portanto, vejam os Senhores - e isso se deu num *habeas corpus*, já poderia ter sido verificado antes, já temos duas condenações em segundo grau. E aí, quando nós vemos as informações de que a competência de Curitiba tinha que ser expandida, a despeito da decisão do Plenário, já de 2015/2016, dizendo que os fatos não guardavam relação com a corrupção da Petrobras.

Então, eu vou retomar esses fatos simplesmente em homenagem ao cuidadoso voto agora proferido pelo Ministro Nunes Marques. Eu passo a esses fatos e digo, portanto, que nós sempre placitamos que o HC serve, sim, como instrumento de revisão criminal. Vou então fazer essa retomada dos fatos, passando, primeiro, pela condução coercitiva de Luiz Inácio Lula da Silva. E, depois, o próprio Tribunal disse que aquela montanha de conduções coercitivas era ilegal. Nós placitamos isso no Plenário.

"O primeiro fato indicador da parcialidade do magistrado consiste em decisão datada de 04.03.2016 que ordenou a realização de uma espetaculosa condução coercitiva do então investigado, sem que fosse oportunizada previamente a sua intimação pessoal para comparecimento em juízo, na forma do exigido pelo art. 260 do Código de Processo Penal:

'Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença.'

Cumpre observar que, antes da realização desse ato, o paciente já havia sido intimado e prestado depoimento em pelo menos outras 4 (quatro) vezes. Ou seja, sempre houve o cumprimento espontâneo por parte do então investigado.

O que justificaria então a solução conferida pelo magistrado de submeter o ex-presidente ao constrangimento de uma condução sob vara? A leitura da decisão assinada pelo ex-juiz a um só tempo revela que o procedimento ali adotado era sui generis e que a sua escolha se dava pela exposição pública do ex-Presidente Lula. Nesse sentido, o magistrado

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557